

1501388-62.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 - "Lei de Execução Penal" que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501388-62.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501388-62.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284613/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20897199 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2481/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2284613 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ANDRADE GONCALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA, processada pelo procedimento especial previsto na Lei de Drogas, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face das rés JULIANA XAVIER CAVALCANTE e GISLAINE APARECIDA DUARTE DA SILVA, bem como do acusado TIAGO ANDRADE GONÇALVES, devidamente qualificados nos autos, imputando a eles a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, ambos c.c. artigo 61, II, "j", na forma do art. 69, ambos do do Código Penal, eis que: 1) no mês de outubro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 19 de outubro de 2021, por volta de 02h40, na rua Antônio de Souza Quevedo, altura do nº 197, Vila Angélica, nesta cidade e

Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, transportavam, traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 01 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 10 gramas; 09 porções de cocaína, embaladas em microtubos, com peso bruto aproximado de 5 gramas; e 05 porções de cocaína, embaladas em microtubos, com peso bruto aproximado de 3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados praticavam o tráfico, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, faziam uso do veículo marca "GM", modelo "Corsa Wind", cor branca, placas CIQ7910/Tatuí/SP, para a distribuição das drogas e a coleta do dinheiro arrecadado, pelo bairro Vila Angélica.

Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de que os acusados estavam fazendo entregas de entorpecentes e coletas de valores, sendo que a informação dava conta do local onde o automóvel estava estacionado. Os agentes públicos, então, avistaram o veículo, com os denunciados no seu interior. Houve a abordagem e, em revista pessoal, com GISLAINE foi localizada 01 porção grande de cocaína, bem como a bolsa contendo cartão bancário e R\$1.865,60. Com TIAGO, foram encontrados, em suas roupas íntimas, R\$5,00 e 05 porções de cocaína. Por fim, com JULIANA, foram localizados R\$40,00 e 09 porções de cocaína, também escondidas nas vestes íntimas.

Notificados (fls. 164, 177 e 202), os réus apresentaram Defesas Preliminares (fls. 143/145, 186/192 e 210), procedendo-se, então, o regular recebimento da denúncia em 04 de maio de 2022 (fls. 213/216). Durante a instrução, foram ouvidas cinco testemunhas e as rés foram interrogadas, tudo gravado em audiovisual. O réu Thiago, embora intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos réus nos termos da exordial.

A Defesa do réu Tiago sustentou, preliminarmente, a falta de observância do artigo 367 do CPP, devendo ser afastada a decretação de revelia. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado (fls. 268/271).

A Defesa da ré Gislaíne requereu a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação do §4º do artigo 33 da mesma Lei. Em relação ao delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, requereu a absolvição (fls. 272/281).

A Defesa da ré Juliana requereu a absolvição pela insuficiência probatória; subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 282/293).

Folha de antecedentes a fls. 38/40, 42/43 e 46/48, bem como certidões a fls. 35/37, 41 e 44/45.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pela Defesa do acusado Tiago, uma vez que o oficial de justiça compareceu em duas ocasiões no endereço por ele informado, não logrando êxito em encontrá-lo (fls. 249). Cumpre observar que cabia ao réu manter seu endereço atualizado nos autos.

No mais, o pedido acusatório merece ser julgado parcialmente procedente. Vejamos:

É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados)

No entanto, para que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter

permanente, estável e duradouro.

Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)" (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)

Neste mesmo sentido, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)" (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103)

Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, nota-se que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que eles pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente.

Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse mapeado com precisão as divisões de incumbências da suposta associação criminosa, tampouco foram apreendidas anotações da traficância ou instrumentos para acondicionamento de drogas, circunstâncias que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente.

Como se vê, pela inexistência de outras provas, é necessário considerar que o envolvimento dos réus foi episódico e eventual nessa prática delitiva, não havendo provas do animus associativo entre eles.

E, portanto, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação preliminar (fls. 08/09), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 152/154) e pelas demais provas acostadas nos autos.

A autoria é igualmente evidente e clara, a despeito dos acusados terem negado peremptoriamente a prática dos fatos. Senão vejamos:

O réu TIAGO, em solo policial (fls. 13), negou o delito de tráfico e disse que a droga encontrada com ele era para seu uso próprio, pois é usuário de cocaína. Estava no bar bebendo com as duas mulheres e somente iria dar carona para elas. Não sabia que as duas mulheres estavam portando drogas e que as conheceu naquela ocasião.

Por sua vez, a ré JULIANA, em solo policial (fls. 14), manteve-se silente. Em juízo, disse que era aniversário dela, ela havia ido a Boituva e comprou 12 pinos de cocaína. A droga foi encontrada dentro de um maço de cigarros, no sutiã dela. Era para uso próprio. Encontrou Tiago e Gislaine ali no momento, no bar, não os conhecia antes. Não sabia que eles tinham drogas também. O carro em que estavam era do Tiago. Não sabe para onde estavam indo, iam parar em algum lugar. Não se lembra

muito bem, porque estava muito alcoolizada. Disse que é usuária de drogas há cerca de dois anos.

Finalmente, a ré GISLAINE, em solo policial (fls. 15), manteve-se silente. Em juízo, disse que foram abordados quando estavam comemorando o aniversário da Juliana. O dinheiro que estava com ela era pagamento que recebeu em adiantamento da patroa dela, para comemorar o aniversário da amiga Juliana. Estava fora do carro quando foi abordada. A droga não estava dentro da bolsa dela, estava na mão dela, era para uso deles. Conhecia a Juliana ali da lanchonete que frequentavam, de outro dia. O Tiago ela não conhecia, ele apareceu ali no momento e ofereceu carona. Havia ido para Boituva pegar drogas com a Juliana, de moto. É usuária de drogas há dois anos. Não se recorda quantos anos a Juliana estava fazendo, nem quantas porções de droga havia comprado.

Analisando as autodefesas das rés - colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que, a despeito da admissão da posse de drogas, negaram a destinação comercial dos entorpecentes. Ocorre que as versões apresentadas pelas acusadas são contraditórias, sendo a negativa é inverossímil e sem qualquer lastro probatório. Pelo contrário, foi afastada pela prova produzida nos autos.

De fato, o Policial Militar Filipe Araujo Colangelo, em sede policial (fls. 10/11), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento e, então, a equipe foi solicitada por um transeunte nas proximidades do Bairro Vila Angélica, que não quis se identificar. Essa pessoa delatou que, na Rua Antônio De Souza Quevedo, havia um veículo corsa branco estacionado e que os ocupantes do veículo estariam realizando a distribuição de drogas pelo bairro, bem como recolhendo o dinheiro do tráfico. Foram até o local informado, onde visualizaram o veículo estacionado conforme a "denúncia". Foi realizada a abordagem nos ocupantes, sendo 2 mulheres e 1 homem. Com GISLAINE, foi localizada uma porção grande aparentando ser cocaína e uma bolsa de mão contendo 1 cartão bancário da caixa econômica federal (Programa Bolsa Família) em seu nome, além da quantia de R\$ 1.865,60 em dinheiro, sendo diversas notas. Instada, GISLAINE alegou que a bolsa e a droga eram de TIAGO e que este estaria fazendo o "recolhe" do tráfico. Com TIAGO, foram localizadas a quantia de R\$ 5,00 e 05 pinos aparentando ser cocaína em sua roupa íntima. Com JULIANA, foram localizados 9 pinos de cocaína no sutiã e a quantia de R\$ 40,00. Acrescentou que foi solicitado apoio de uma policial feminina para realizar a revista nas mulheres. Instados, JULIANA e TIAGO alegaram que são usuários de cocaína e que desconhecem a origem do dinheiro que GISLAINE estava portando. Em juízo, narrou que estavam em patrulhamento, quando uma pessoa informou que tinha um veículo Corsa branco com pessoas "distribuindo e recolhendo dinheiro do tráfico". Realizaram a abordagem, havia duas mulheres e um homem. Com a Gislaine, encontraram uma porção grande de cocaína e um valor de 1865 reais, além de um cartão bancário. Com Thiago, encontraram 5 reais e 5 porções de cocaína. Com Juliana, encontraram 40 reais e 9 porções de cocaína. Gislaine disse que a droga era do Thiago e que ele estava fazendo o recolhe do tráfico. Thiago e Juliana disseram que eram usuários. Desconhecia Thiago e Juliana. Gislaine conhecia porque havia prendido o filho dela semanas antes.

Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Leandro Rogerio Delfino Martins, em sede policial (fls. 12), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento quando uma pessoa falou que havia um Corsa branco comercializando drogas. Visualizaram o veículo, onde havia duas mulheres e um homem no interior. Em revista pessoal, localizaram com a Gislaine dinheiro, uma porção grande de cocaína e um cartão com o nome dela. Ela afirmou que tudo era do Thiago. Com o Thiago, foram localizados 5 pinos de cocaína em sua cueca e cinco reais. Com a Juliana, havia 9 pinos de cocaína no sutiã, além de dinheiro. Ambos (Thiago e Juliana) disseram que eram usuários. Antes desse dia, não conhecia os réus, exceto Gislaine, em razão de uma ocorrência de tráfico relacionada ao filho dela.

Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às

versões judiciais de demais testemunhas.

Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente os réus ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório.

Neste sentido:

Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu
Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados).

De outro lado, a informante Nailene Xavier de Oliveira, mãe da ré Juliana, em juízo, disse que a ré é uma boa filha. Depois da prisão dela, teve ciência de que ela estava usando drogas.

Por sua vez, a testemunha Marcos Paulo de Oliveira Ribeiro, primo da ré Juliana, em sede judicial, disse que a ré é uma pessoa batalhadora, tem uma filha. Não sabia que ela era usuária de drogas, mas desconfiava. Hoje, a família está procurando ajuda.

Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes.

Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo e transportavam as drogas apreendidas, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas em poder de TIAGO, GISLAINE e JULIANA; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 152/154), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente.

Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado.

Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida.

Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 3) a exata correspondência das características dos traficantes apontados em delação anônima, com a do réu e as das rés; e 4) a informação dos policiais, de que, informalmente, a ré GISLAINE admitiu que o acusado TIAGO estava recolhendo o dinheiro obtido com a venda de drogas.

Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte:

“Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela,

envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588).

Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 152/154) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e transportar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado.

Certo, portanto, que os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta.

I – DO RÉU TIAGO

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 35 (proc. 0001191-90.2010.8.26.0338) se refere a ação penal em curso e observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a

valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, tratando-se de réu reincidente específico (Processo nº 0001326-15.2018.8.26.0535, fls. 35/36), deve incidir a agravante de reincidência. E, portanto, agravo sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena.

Cabe ressaltar que a inviabilidade da incidência da atenuante de confissão, pois a admissão da posse das drogas, acompanhada de alegação de para uso próprio, por expressar confissão de crime diverso do qual é condenado, não se presta a caracterizar a atenuante em questão (Súmula nº 630 do C. STJ).

E mais, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet.

Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu reincidente específico, não preenchendo os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pela norma em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratar de réu reincidente específico, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu.

A quantidade de pena aplicada impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal.

II – DA RÉ JULIANA

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, motivo pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes a incidir, mantenho sua pena inalterada em sua fase.

Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública, pelas mesmas razões expostas anteriormente.

Na terceira etapa, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2. O patamar será intermediário, em razão da nocividade de entorpecentes traficados (cocaína). Nessa esteira, fixa sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que a ré inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pela nocividade do entorpecente traficado.

Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 - "Lei de Execução Penal" que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas").

Desde então, esse Juízo tem deixado de fixar, em tais casos, o regime mais severo para o início do cumprimento da pena, passando a estabelecer o regime inicial intermediário, conforme in casu.

Inviável, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada as circunstâncias judiciais desfavoráveis exaustivamente expostas (nocividade de entorpecentes).

II - DA RÉ GISLAINE

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, motivo pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes a incidir, mantenho sua pena inalterada em sua fase.

Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública, pelas mesmas razões expostas anteriormente.

Na terceira etapa, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2. O patamar será intermediário, em razão da nocividade de entorpecentes traficados (cocaína). Nessa esteira, fixa sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que a ré inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a gravidade concreta do delito, revelada pela nocividade do entorpecente traficado.

Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 - "Lei de Execução Penal" que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas").

Desde então, esse Juízo tem deixado de fixar, em tais casos, o regime mais severo para o início do cumprimento da pena, passando a estabelecer o regime inicial intermediário, conforme in casu.

Inviável, no entanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dada as circunstâncias judiciais desfavoráveis exaustivamente expostas (nocividade de entorpecentes).

III - DO DISPOSITIVO E DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu TIAGO ANDRADE GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar a ré JULIANA XAVIER CAVALCANTE e a acusada GISLAINE APARECIDA DUARTE DA SILVA, ambas devidamente qualificadas nos autos, como

incursas no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 3) absolver o réu e as acusadas da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que os acusados responderam a esse feito em liberdade e não sobrevieram razões que exigissem a segregação cautelar deles. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu e das acusadas, bem como guia de recolhimento quanto a todos, bem como arquivem-se os autos. Isento o réu TIAGO do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensores dativos (fls. 204).

Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intuem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da condenação, fica ainda obrigadas as rés GISLAINE e JULIANA a recolherem custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhes concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois constituíram advogados (fls. 113 e 193), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade delas de suportar o ônus financeiro das custas processuais.

Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa e o montante referente às custas processuais. Após, intime-se as acusadas GISLAINE e JULIANA para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 132) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 1.910,60 em dinheiro - fls. 178) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa, conforme prova oral revelando que o montante é resultado do exercício da traficância realizado pelo acusado e pelas rés.

Escorada na mesma fundamentação legal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 132) e DECRETO a perda do veículo apreendido (GM/Corsa Wind, de placas CIQ 7910 Tatui/SP - fls. 07), em favor da união, apropriado ao Funad, posto que se comprovou que este veículo era empregado pelos réus para o transporte e entrega de drogas.

Destaque-se, em se tratando de bem móvel, presume-se que o possuidor do veículo - in casu o réu - é seu proprietário e, portanto, a indicação de outra pessoa no registro do automóvel não obsta a decretação do perdimento deste bem, pois tal discrepância constitui mera irregularidade administrativa. Até mesmo porque, comprovada a utilização do bem para o exercício da narcotraficância, a identificação de seu titular, para fins de perdimento, é irrelevante.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00172372320118260047 SP 0017237-23.2011.8.26.0047, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 31/01/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2013) (grifos aditados)

Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei.

Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP.

P.I.C.

Tatui, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA